

1502478-89.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2280906/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 20827928 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3273/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2280906

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502478-89.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502478-89.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2280906/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 20827928 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3273/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2280906

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GENIVALDO DE SANTANA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Genivaldo de Santana Junior, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 14 de outubro de 2021, por volta de 16h20min, na Rua São Carlos, altura do nº 26-B, Jd. dos Reis, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, o Réu trazia consigo e guardava, para fins de venda, as seguintes drogas: a) 134 porções de maconha, pesando, aproximadamente, 371g de massa bruta; b) 16 "pedras" de crack, pesando, aproximadamente, 18g de massa bruta c) 41 porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 21g de massa bruta; substâncias causadoras de dependência física e

psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 34,00 (trinta e quatro reais) em notas trocadas.

Laudo de exame pericial prévio de constatação da droga às fls. 16/21.

A denúncia foi recebida à fl. 53, em 22 de outubro de 2021.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 59/60.

Regularmente citado e notificado (fl. 68), o Réu apresentou defesa prévia às fls. 71/72.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 85/87.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Rodrigo Vettori e William da Silva Dias, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais escritas pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 113/119 e 126/170, respectivamente.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

Destaco que a alegação de nulidade probatória suscitada pela Defesa se confunde com o mérito, e, portanto, com este será analisado.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 08/09, pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 16/21 e fls. 85/87, respectivamente.

A autoria do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha William da Silva Dias, guarda municipal, narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento por local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, quando avistaram o Réu, que tentou empreender fuga. Conseguiram alcançá-lo e encontraram em sua posse sacola com drogas e dinheiro fracionado. Em data anterior, o declarante realizou a prisão do acusado pelo mesmo crime. No dia em questão, ele não tentou dispensar a sacola. No momento em que chegaram ao local, havia somente o Réu, que estava parado próximo a um muro. No mesmo sentido, a testemunha Rodrigo Vettori, guarda municipal, relatou que estava em patrulhamento preventivo pela Rua São Carlos, local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, quando avistou o Réu, que, tão logo percebeu a presença da guarda, tentou se evadir. Ato contínuo, os policiais apreenderam a sacola que estava em sua posse e detiveram o acusado. No interior do referido objeto, havia drogas diversas e quantidade de dinheiro em notas fracionadas. A sacola foi encontrada na mão do Réu. Não havia outras pessoas no local, além do acusado.

Com efeito, a prova oral colhida, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamenta o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Os depoimentos dos guardas municipais que participaram das diligências fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional. Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Assim, o depoimento dos guardas municipais só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os guardas municipais abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista esse se encontrava em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes e, ao avistar os agentes públicos, tentou imediatamente empreender fuga -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se, ainda, que os guardas municipais, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Por outro lado, em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Narrou que, por causa da pandemia, perdeu o seu emprego e passou a morar nas ruas. Quando foi preso, estava trabalhando com reciclagem. Ganhava o suficiente para almoçar e jantar. Acabou se envolvendo com drogas e, no dia dos fatos, estava no local da ocorrência na posição de olheiro. Aceitou trabalhar em tal posição para juntar dinheiro para voltar para o Piauí. A sacola encontrada pelos guardas municipais não estava em sua posse. Quando avisou a chegada da guarda no local, os traficantes saíram correndo e deixaram a sacola no local. Havia várias outras pessoas no local quando os guardas chegaram.

Em que pese a versão exculpatória apresentada pelo Réu, essa se encontra dissociada do restante do conjunto probatório e da realidade fática, não sendo crível que guardas municipais tivessem tentado lhe atribuir a posse de drogas à revelia da lei, sem motivo concreto para tanto e, ainda, colocar em sua posse a quantia de R\$ 34,00 (trinta e quatro reais), conforme auto de exibição/apreensão de fls. 08/09. Do mesmo modo, é inverossímil que os “verdadeiros traficantes” da localidade, ao fugirem, teriam dispensado sacola com drogas e dinheiro no exato local em que estava o acusado, e não carregado consigo, uma vez que sequer foram perseguidos pelos guardas municipais.

No mais, as testemunhas de acusação foram uníssonas em apontar que a referida sacola foi encontrada nas mãos do Réu, não havendo quaisquer contradições em seus relatos - bem como razões idôneas - que permitam concluir pela prática de flagrante forjado.

No que tange à licitude da prova, em que pese guardas municipais não possuírem atribuições constitucionais para realizar investigação criminal, qualquer pessoa do povo pode realizar prisão em flagrante delito, consoante art. 301, CPP. No caso, os agentes públicos atuaram em local público (via pública), conhecido pela prática de venda de entorpecentes, em situação que não exigia a expedição de mandado ou aprofundamento das investigações por parte dos órgãos competentes.

Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de trancamento da ação. Impossibilidade. Paciente e corréus que estavam em atitude suspeita, transportando entorpecentes.

Situação de flagrância. Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais (art. 301 do CPP) Precedentes Ordem denegada". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2065756-68.2013.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2014; Data de Registro: 11/08/2014).

"Apelação. Tráfico de entorpecentes. Preliminar. Alegada nulidade da prova colhida pela guarda municipal. Inexistência de ilicitude da prova. Guarda municipal prevista no art. 144, § 8º, da CF, e regulamentada pela Lei 13.022/14. Expressa previsão de prisão em flagrante e encaminhamento ao delegado de polícia. Outrossim, por expressa previsão do art. 301 do CPP, cabe a qualquer do povo prender quem se encontre em flagrante delito. Seria um contrassenso autorizar qualquer cidadão a realizar a prisão em flagrante e impedir que a guarda municipal o fizesse. Prova lícita. Preliminar rejeitada. Ausência de impugnação quanto à dinâmica dos fatos. Réu confesso. Penas. Redução. Necessidade. (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1501482-56.2020.8.26.0567; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2021; Data de Registro: 30/05/2021).

Logo, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a atuação dos agentes públicos ocorreu em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, não extrapolando os limites constitucionais de sua atuação.

No que tange à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto pulverizadas em pequenas porções (consoante auto de exibição de fls. 08/09, em mais de quatrocentas unidades individualizadas), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros. Além disso, a dinâmica dos fatos – consubstanciada no fato de o Réu se encontrar na posse de quantia em dinheiro, em notas trocadas, tendo tentado empreender fuga tão logo avistou os guardas municipais – não permite a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06).

Deste modo, inviável a desclassificação para os crimes de porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06) ou colaboração com o tráfico (art. 37, Lei nº 11.343/06), ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço, bem como os relatos dos guardas municipais vinculando as drogas apreendidas à conduta do acusado.

Logo, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, ilicitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, estabeleço a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de provas que permitam inferir circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Destaco que a quantidade da droga (218,47g líquidos – fls. 17/18) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em segunda fase da dosimetria, não incidem agravantes ou atenuantes. Deixo de aplicar o disposto no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em razão de o delito não guardar relação com a situação de calamidade pública – essa não facilitou, influenciou nem foi causa para a prática do delito. Do mesmo modo, deixo de aplicar a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), com fundamento na ratio da Súmula nº 630, STJ, uma vez que o Réu não admitiu a prática do tráfico nem a posse dos entorpecentes, aduzindo tão somente que se encontrava no local na qualidade de colaborador ("olheiro"). Logo, mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, no que se refere à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que o Réu não preenche os requisitos exigidos, em especial, a não dedicação a atividades de tráfico.

Isto, pois o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que a (i) reincidência, (ii) os maus antecedentes e (iii) a dedicação a atividades criminosas e/ou

integração a organização criminosa são empecilhos à incidência da causa de diminuição de pena, compreendendo-se que, diferentemente das duas primeiras, a dedicação ao tráfico não requer a existência de condenação prévia com trânsito em julgado, podendo, portanto, restar configurada por meio de outras provas produzidas no curso da instrução.

Neste sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o afastamento do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com a utilização de ações penais em curso, desde que haja sentença ou outros indicativos de que o acusado se dedica à atividade criminosa, tal qual é o caso dos autos, vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque 'assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito'. Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.”. (STJ; Embargos de Divergência em REsp nº 1.431.091/SP (2014/0015576-0), Min. Sebastião Reis Júnior; 6ª Turma).

Como, no presente caso, o Réu já foi condenado por sentença não transitada em julgado nos autos do processo nº 0000659-94.2021.8.26.0544, por fato idêntico ao sob exame, em data anterior e próxima à da prática do tráfico em questão, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, por se tratar de prova de que a conduta do Réu não era eventual e/ou esporádica.

Portanto, à míngua de outras circunstâncias modificadoras da reprimenda penal, estabeleço a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime semiaberto como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, por se tratar de Réu tecnicamente primário e de as circunstâncias judiciais não serem desfavoráveis.

Deixo de substituir a pena por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos legais (art. 44, CP), em especial, o quantum de pena aplicado. No mesmo sentido, o Réu não faz jus à suspensão da pena, com fundamento no art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Genivaldo Santana Junior como incurso nas penas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 387, CPP, CONDENANDO-O ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecidos no valor mínimo legal, atualizados desde a

prática delitiva.

Tendo em vista que o Réu foi encontrado na posse de R\$ 34,00 (trinta e quatro reais), praticando o delito de tráfico, determino o seu perdimento, à luz do art. 63, I, Lei nº 11.343/06, porquanto inexistentes nos autos provas que permitam inferir que tal quantia não se originou das vendas realizadas no âmbito do crime em questão.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Defiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP) à luz do princípio da proporcionalidade e homogeneidade das penas, tendo em vista o quantum de pena aplicado, o seu respectivo regime inicial semiaberto. Expeça-se alvará de soltura clausulado, constando que o acusado deverá comparecer mensalmente ao fórum para justificar atividades, sob pena de revogação da liberdade provisória.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Franco da Rocha, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA